

1501687-50.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... relação ao crime de associação para o tráfico de drogas e condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, com a possibilidade de aplicação do benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas à Odenice.

A defesa requereu a absolvição por falta de provas de ambas as rés em relação ao crime de associação para o tráfico e da ré Elza Santos de Almeida pelo crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501687-50.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501687-50.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELZA SANTOS DE ALMEIDA e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face ODENICE MICHEL DE JESUS CONCEIÇÃO E ELZA SANTOS DE ALMEIDA, já qualificadas nos autos, como incursas no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, em data anterior a 23 de outubro de 2021, em local e horários indeterminados, as acusadas teriam se associado para o fim de praticar o tráfico ilegal de drogas.

Constam também que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 14h00min, na Av. Santa Casa, n. 566, Vila Martins, nas imediações do Hospital Santa Casa de Penápolis, nesta cidade e comarca de Penápolis, as acusadas, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, adquiriram, transportavam e traziam consigo uma porção de maconha (15,44g), bem como cinco porções de crack (17,86g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia no dia 27 de outubro de 2021 (fls. 159/160).

A ré Elza Santos de Almeida foi citada (fls. 193). A ré Odenice Michel de Jesus Conceição compareceu aos autos espontaneamente. Ambas apresentaram defesa em

conjunto, alegando inocência. Pugnam pelo afastamento do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e ao final interrogadas as rés. Em alegações finais o Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, pugnando pela absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas e condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, com a possibilidade de aplicação do benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas à Odenice. A defesa requereu a absolvição por falta de provas de ambas as rés em relação ao crime de associação para o tráfico e da ré Elza Santos de Almeida pelo crime de tráfico de drogas. Em relação à ré Odenice pugnou pela concessão do benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e pelo afastamento da causa de aumento de pena (fls. 266/271).

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do delito de tráfico de drogas é positiva, tal como se extrai do BO de fls. 73/75, do auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, dos laudos de constatação de fls. 37/42 e 43/48 e dos exames toxicológicos definitivos de fls. 137/139 e 140/142, que identificaram 15,44 gramas de maconha e 17,86 gramas de cocaína na forma de crack.

Em relação à autoria necessário analisar a prova oral produzida.

Em juízo a testemunha Walter Ruiz Bogaz Neto, confirmando seu depoimento na fase administrativa (fls. 08), disse que no dia dos fatos receberam informações de investigadores da região que estava tendo um possível tráfico de drogas em frente ao Hospital. Não tinha informações anteriores das rés. Fizeram uma campana e pegaram elas. No local estavam visualizando tanto um quanto a outra ré. As duas estavam em contato. No momento em que as duas começaram a conversar, recebeu informações de outros investigadores. Abordaram elas. Retiraram elas do local. Colocaram elas em outro local para não gerar constrangimento e fizeram a busca pessoal. Foi uma escrivã de polícia que encontrou a droga. O delegado Thales estava junto, Manoel e Gilmar, policiais civis, também estavam no local. Encontraram dinheiro significativo com Odenice, com Elza não. Não se recorda com qual das duas estava o dinheiro. Fizeram o acompanhamento. Esperaram um pouco para não constranger as rés, aguardando o melhor momento. Estavam seguindo ordem do delegado e dos demais colegas de equipe.

A testemunha Manoel Izael de Oliveira, confirmando seu depoimento na fase administrativa (fls. 06), disse que conhece Elza, já foi presa uma vez por tráfico. Elza foi para Ibitinga, depois voltou para Luiziânia, fazendo tráfico. Não tem conhecimento de Odenice, só do marido dela, que é filho de Elza. Só esse dia que chegou a denúncia anônima de que Odenice trazia droga. Seguiram Elza que saiu de Luiziânia e foi até Penápolis com o ônibus da prefeitura. Depois chegou a Odenice. A escrivã fez revista nas duas e encontrou droga com Odenice. Elas foram conduzidas até a delegacia de Penápolis. Elza que confessou que a droga era dela. A informação que o depoente teve era que a droga ia ser trazida para Elza. Odenice informalmente depois disse que a droga era da Elza, primeiro disse que não queria falar, mas depois disse que a droga era da Elza. Elas estavam no banco, quando chegaram perto Odenice estava saindo do local. Quando o depoente foi para o lado de Odenice ela reconheceu. Só foi falar com ela no momento da abordagem, antes estava dentro do carro escondido.

Na fase administrativa a ré Odenice Michel de Jesus Conceição disse que "Tem apelido de "Tita". Sobre os motivos da sua prisão, quer dizer apenas "a droga foi encontrada comigo, mas não quero dizer quem é o seu proprietário, pois tenho medo de morrer". Não possui passagens criminais. Elza dos Santos é sua sogra. Elza tem apelido de "Baiana". Questionada, confirma que estava presente quando Elza disse que a droga lhe pertencia, mas não quer dar maiores detalhes. Apenas volta a dizer que não é sua a droga. Afirma que não ganhou nada para trazer a droga até o estacionamento da Santa Casa de Penápolis. A filha Emily Gabrielly ficará sob os cuidados da prima da interroganda, Maria Isabel Sousa de Jesus, moradora de Luiziânia, 18 anos de idade. Atualmente faz faxinas na casa da Solange de Orcandes,

em Ibitinga. Ganha R\$ 1.000,00 aproximadamente por mês. Questionada sobre o que veio fazer em Penápolis, disse "vim trazer o negócio". Novamente indagada, esclarece que "negócio" trata-se da "maconha " e da "pedra" apreendidas. Questionada sobre para quem entregaria a droga, afirma "não posso dizer, minha cabeça está em jogo e não verei minha filha crescer". Não possui filhos com deficiência. Afirma que os R\$ 102,00 localizados consigo são oriundos do Bolsa Família. Autoriza o acesso ao celular apreendido , afirma que não tem nada comprometedor. Desbloqueou o aparelho. Dada a palavra ao procurador, sem reperguntas." (fls. 11). Em juízo disse que está arrependida, se fosse hoje não fazia isso mais. Agiu pela emoção e se arrepende. Morava em Luiziziânia, veio embora para Ibitinga. Foi a primeira vez que trouxe droga. A droga realmente foi encontrada com a depoente. Não é usuária de drogas.

Na fase administrativa a ré Elza Santos de Almeida disse que "Tem apelido de "Bahiana". Sobre as imputações, deseja se manifestar e nega a prática do crime. Nega ter dito que a droga encontrada com Odenice , sua nora, lhe pertence. Afirma que se encontrou com Odenice no hospital porque é lá que o ônibus da Prefeitura de Luiziziânia para descer os passageiros. Não é traficante de drogas. É usuária de maconha. Atualmente trabalha na roça em Luiziziânia e ganha por dia aproximadamente R\$ 30,00. Não sabe dizer de quem é a droga que foi localizada nas vestes de Odenice. Questionada , afirma que Odenice lhe contou que veio para Penápolis nesta data "para trabalhar na roça". Possui passagem por tráfico de drogas. Está respondendo em liberdade. Não possui filho com deficiência. Pede que lhe seja fornecido na carceragem o medicamento "Diazepam" ou "Clonazepam", pois não consegue dormir se não estiver medicada. Tem fobia e falta de ar. Quanto ao dinheiro apreendido, afirma que tinha R\$ 35,00 que ganhou do marido e nesta data sacou R\$ 300,00 na CEF de Luiziziânia para pagar despesas de casa que adquiriu junto à CDHU. Dada a palavra ao procurador, sem perguntas" (fls. 14). Em juízo permaneceu em silêncio.

Pois bem.

A droga apreendida foi encontrada na posse da ré Odenice.

A ré Odenice confessa que trouxe a droga de Ibitinga-SP para Penápolis-SP. O transporte da droga entre municípios e a diversidade de droga (maconha e crack) revelam que o intuito da ré era o comércio espúrio.

Assim, não há dúvidas de que Odenice merece ser condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação à ré Elza Santos de Almeida, porém, não há prova suficiente acerca da autoria. Em verdade, na campana realizada pelos policiais não houve qualquer visualização de ato indicativo de que Elza receberia a droga em questão ou estivesse ali para tanto.

O único indício de autoria parte da declaração informal de Elza no momento da prisão, de que a droga era sua ao mesmo tempo em que disse que a criança não poderia ficar sozinha. Por sua vez, Odenice também teria dito informalmente que a droga era de Elza.

Ora, a acusação recíproca entre corrés não pode ser levada em consideração como prova suficiente para a condenação, já que possível a imputação do delito ao outro a fim de safar-se. Ademais, no presente caso, a presença da criança de tenra idade no local, filha de Odenice e neta de Elza, pode ter gerado o ímpeto de proteger a mãe da criança.

Ou seja, na falta de provas concretas da participação de Elza na traficância da droga que foi encontrada na posse de Odenice Elza merece ser absolvida por falta de provas.

No mais, não há qualquer prova de que as rés associaram-se de forma estável para a prática do tráfico de drogas, tanto que Elza será absolvida do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Assim, de rigor também a absolvição de ambas as rés em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Indo em frente, a ré Odenice é primária, não possuindo maus antecedentes. Também não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sendo assim, de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Aplico a minorante no máximo legal.

Por fim, como o crime foi praticado em frente à Santa Casa de Penápolis, de rigor a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, no mínimo legal.

Passo à dosimetria da pena.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/10 (um décimo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/10 (um décimo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas por força do art. 59 do CP, mais duas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga).

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena, até a fim de prestigiar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas em relação às demais circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais.

O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas prevê pena de reclusão de 05 a 15 anos e de 500 a 1500 dias-multa.

Em relação à quantidade da droga apreendida nada a valorar. A natureza da droga merece valoração negativa, já que houve a apreensão de crack, droga de alto poder viciante, extremamente maléfica à saúde humana. A culpabilidade é exacerbada, posto que a ré levou junto sua filha de tenra idade para a prática delitiva. A ré não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é normal à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal. Finalmente, não há que se valorar o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago, em que a vítima é a sociedade como um todo.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ausente qualquer agravante. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Presente a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tal como já fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando a pena final em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o dia-multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, que previa necessariamente o regime inicial fechado para os crimes hediondos.

Ademais, no HC 118.533, recentemente o STF firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo.

Sendo assim, nos termos do art. 33, §3º e 5º, ambos do CP, tendo em vista a pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO (ART. 33, do CP).

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, nos termos a serem definidos pelo juiz da execução.

A ré poderá recorrer em liberdade, vez que ausentes motivos para a segregação cautelar no momento, diante do regime e da substituição por pena restritiva de direitos autorizada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim CONDENAR a ré ODENICE MICHEL DE JESUS CONCEIÇÃO, pela prática do delito de tráfico "privilegiado" de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas), e, por consequência, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

No mais, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolvo ambas as rés do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas e ELZA SANTOS DE ALMEIDA em relação à acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas).

Expeça-se alvará de soltura clausulado em relação à ELZA SANTOS DE ALMEIDA.

Disposições finais:

a) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial.

b) Decreto o perdimento do dinheiro encontrado na posse de Odenice (R\$ 102,00) e de seu celular, pois produto do crime e instrumento utilizado para a traficância, tudo nos termos dos arts. 63, §1º, e 64 e da Lei de Drogas.

c) Determino a restituição à ré Elza Santos de Almeida da quantia apreendida em sua posse (R\$ 335,00) e de seu celular.

Condeno a ré Odenice ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante da situação financeira apresentada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a multa, intimando-se para pagamento; c) Expeça-se guia de recolhimento; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.

Penápolis, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA